

1500816-80.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... - certidões de pp. 90 e 240) e roubo majorado (autos nº 1521787-81.2017.826.0562 - certidões de pp. 91 e 240).

Ademais, ostenta uma condenação definitiva antiga pelo crime de roubo majorado (autos nº 0016419-15.2010.8.26.0562 - certidões de pp. 90 e 239), a qual, ainda que não sirva para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500816-80.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500816-80.2022.8.26.0536 - Controle n.º 186/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO GOMES DE MOURA e GILBERTO OLIVEIRA RIBAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

MARCELO GOMES DE MOURA e GILBERTO OLIVEIRA RIBAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta de 2h25min, na Praça dos Andradas, neste município e comarca, para proveito comum, subtraíram 4 (quatro) conduítes do quadro de eletricidade pertencente à Prefeitura Municipal de Santos.

Diz a denúncia que, durante o período de repouso noturno, os acusados se aproximaram do quadro de eletricidade instalado na Praça dos Andradas e, enquanto um segurava o gradil, o outro cortava a fiação lá existente e retirava as peças (conduítes). Com o auxílio de ferramentas (alicates), os réus conseguiram cortar e subtrair quatro conduítes do quadro de energia elétrica que estava instalado na Praça.

Consta, ainda, que guardas municipais que realizavam patrulhamento foram acionados, via rádio, para se dirigirem ao local e, lá chegando, avistaram o corréu Gilberto, que foi detido quando tentava fugir dali com uma bicicleta. Em poder dele os guardas municipais apreenderam os conduítes subtraídos e também três alicates, um de corte e dois simples.

No local, os guardas municipais também detiveram o corréu Marcelo que, assim como Gilberto, aparecia nas imagens das câmeras de monitoramento e, em poder dele, apreenderam um alicate de corte (pp. 142/144).

Recebida a denúncia (pp. 145/146), os réus foram citados pessoalmente (pp. 172 e 174). A Defesa ofereceu a resposta de p. 179, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 180/181).

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas, procedendo-se aos interrogatórios (pp. 251/252).

Em alegações finais, por memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. No tocante à reprimenda, pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante dos inúmeros antecedentes criminais que indicam possuírem os réus personalidade voltada à prática de crimes. Ademais, pugnou pelo reconhecimento da agravante da reincidência e sua preponderância em relação à atenuante da confissão, bem como a aplicação da causa de aumento de pena decorrente do repouso noturno. Suscitou, ainda, o reconhecimento da tentativa, pois os réus foram presos ainda no local dos fatos. Ademais, entendeu incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pretendeu a fixação de regime inicial fechado (pp. 291/294).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações escritas, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista que não foram juntadas imagens da ação captadas pelo sistema de monitoramento por câmeras da Prefeitura. Argumentou, ademais, que a confissão precisa ser confirmada por outros meios probatórios, e que não se pode afastar a suspeição que recai sobre os depoimentos dos guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante delito.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que as condenações antigas não devem ser consideradas como maus antecedentes, à luz do princípio da humanidade e da proscrição da perpetuidade das penas. Suscitou, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência. Ademais, pretendeu o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, por se tratar de crime de furto qualificado, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo objeto do tema n.º 1.087. Outrossim, pleiteou o reconhecimento do furto em sua forma tentada, com a diminuição da pena na fração máxima, pois os réus foram surpreendidos no local e a ação foi flagrada por guardas municipais. Por fim, pretendeu a concessão de regime prisional inicial semiaberto (pp. 298/311).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente em parte.

A materialidade está demonstrada no auto de exibição e apreensão de pp. 7/8, auto de entrega de p. 11 e laudo pericial de pp. 281/285.

A autoria também é certa.

Os acusados, ao serem presos em flagrante delito, e apesar da acusação que lhes era dirigida, mantiveram-se calados, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias da prisão (pp. 12 e 13).

Em juízo, ao ser interrogado, o corréu Gilberto admitiu a prática da subtração. Relatou que, dois dias antes do ocorrido, um morador de rua foi eletrocutado ao mexer no quadro de energia, motivo pelo qual o quadro permanecia desligado.

Acreditava que a res não teria mais utilidade e tentou subtraí-la para adquirir drogas. Declarou que mexeu no quadro de energia subterrâneo, mesmo local onde o morador de rua morreu. Não houve tempo de retirar os fios, tendo em vista que uma mulher o avisou da presença dos policiais, e assim tentou fugir com sua bicicleta. Disse que possuía um alicate do tipo lábios de mel. Encontrou o corréu Marcelo no local. Pelo fato de o quadro de energia estar desligado, diversos usuários de entorpecentes tentaram subtrair os fios. Disse que é usuário de drogas e reside com sua esposa grávida e quatro filhos, os quais não possuem deficiência. Na data dos fatos estava com outra mulher, também viciada em drogas. Afirmou que utiliza entorpecente desde os quatorze anos – crack e maconha. Possui a carteira da Citramar e presta serviços no cais. Estudou até a quinta série. Contou que sua

esposa vende cartão de ônibus. Esclareceu que possuía alicates. Estava no interior da parte subterrânea, a qual permanecia aberta, e não chegou a arrancar os cabos (gravação audiovisual, pp. 251/252).

Ao ser interrogado, o corréu Marcelo relatou que era final de mês, período no qual ganha mais dinheiro com a coleta de material reciclável. Saiu debaixo do viaduto às 2h10min e deixou sua esposa, a qual estava usando muleta. Contou que, três dias antes, o morador de rua Gabriel morreu no local em que o corréu Gilberto puxava o fio com o alicate. Disse que sua atuação no furto foi puxar o fio preso do outro lado da praça. Tentou retirar o fio quatro vezes e, como não conseguiu, colocou seu alicate dentro de seu carrinho. Uma usuária de entorpecentes o avisou da chegada de guardas municipais, os quais o abordaram na praça junto da mulher. Declarou que já havia desistido de ajudar o corréu Gilberto e não viu se ele conseguiu retirar os fios. Explicou que se dirigia ao centro da cidade e, no caminho, passou pela praça, local onde todos o conhecem, pois há dois anos recolhe materiais recicláveis por lá. Mencionou que encontrou o corréu Gilberto às 2h15min e havia duas meninas com ele, com suas respectivas bicicletas. Possuía um carrinho de mercado com o alicate em seu interior. A moça que estava ao seu lado não se envolveu na conduta criminosa. Esclareceu que pretendia vender o material para comprar o café da manhã de sua esposa, gastando o que sobrasse em drogas. Consome crack, cocaína, maconha, bala e lança-perfume desde os dezesseis anos de idade. Passou por tratamento quando tinha dezenove anos e permaneceu por dois anos e oito meses sem utilizar entorpecentes. Todavia, voltou a consumir drogas há mais de um ano. Disse residir na casa de sua família, localizada na Rua Santa Elisabete n.º 1.558, Morro do São Bento. Não é casado e possui uma filha de doze anos e um filho de dezessete anos. Nenhum deles tem deficiência. Contou que auxilia seu pai, que é mestre de obras. Estudou até a quarta série (gravação audiovisual, pp. 251/252).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Carlos Elizio Caetano, guarda municipal, relatou que sua equipe estava em patrulhamento no entorno da Praça dos Andradas e o centro de monitoramento da cidade repassou que havia indivíduos cortando um quadro de luz e subtraindo os fios. Deslocaram-se até o local e abordaram os acusados, que confessaram informalmente a conduta, motivo pelo qual os conduziram ao distrito policial. Declarou que havia uma ferramenta no chão, jogada no mato, ferramenta essa que aparecia nas imagens com os indivíduos. Os réus tentaram fugir, mas foram detidos. Um dos acusados utilizou uma bicicleta para tentar a fuga. Ao lado dele, no solo, havia um alicate tesoura de vergalhão, o qual o agente utilizou como se fosse um colar, amarrado numa corda em volta do pescoço, e o arremessou ao solo tão logo foi detido. Informou que o outro réu foi abordado no local onde ocorreu o furto. Esclareceu que, pelas câmeras de vigilância, foi possível observar três ou quatro pessoas no local. Visualizou-se o momento em que cortaram o cadeado do quadro de força e tentaram puxar e cortar os fios. Eles conseguiram cortar alguns fios, mas não conseguiram subtrair todos os fios devido à chegada da Guarda Municipal. Não se recorda dos acusados estarem segurando um gradil. Ao observar os acusados na audiência, realizada por videoconferência, informou que o corréu Gilberto foi quem tentou a fuga de bicicleta. Por sua vez, o corréu Marcelo também possuía um alicate e estava perto dos conduítes. Contou que foi responsável pela detenção do corréu Marcelo, pois a equipe se dividiu. Afirmou que as características físicas e vestimentas dos acusados correspondiam às imagens captadas pelo setor de monitoramento. Narrou que enquanto o outro acusado realizava a subtração, o corréu Gilberto observava se havia alguém se aproximando. Pelas filmagens, foi possível observar que entre os dois havia a distância de um banco. Esclareceu que a filmagem repassada ocorreu após o arrombamento do cadeado. Ao chegarem ao local os acusados ainda lá permaneciam. O corréu Gilberto tentou fugir com uma bicicleta, enquanto o corréu Marcelo disfarçou e acelerou o andar (gravação audiovisual, pp. 251/252). Mário Bruno dos Santos, guarda municipal, afirmou que estavam em patrulhamento no Centro e o setor de monitoramento avistou indivíduos subtraindo um quadro de luz situado no lado esquerdo da praça. Assim, deslocaram-se até o local, realizaram o cerco e capturaram os acusados com os materiais do furto. Recorda-se de ambos os

réus. O corréu Marcelo possuía uma mochila com ferramentas, ao passo que o corréu Gilberto dispensou um alicate lábios de mel ao tentar fugir de bicicleta. Declarou que foi um dos responsáveis pela detenção do corréu Gilberto. Não presenciou os fatos, tendo em vista que souberam do ocorrido por meio do setor de monitoramento. Esclareceu que foram arrancados pedaços de cobre e de fio do quadro de luz. Disse que o setor de monitoramento repassou as características físicas e vestimentas dos agentes. Narrou que, no lado esquerdo da praça, há o quadro de luz e, no lado direito, há grades no solo, nas quais passam os fios pelo subterrâneo, motivo pelo qual o corréu Gilberto atuou do lado esquerdo e o corréu Marcelo do lado direito. Ao chegarem ao local, cada um dos acusados empreendeu fuga pelo lado oposto ao que estavam, e ambos foram capturados. Esclareceu que o monitoramento informou apenas o ato propriamente dito. Não observou a filmagem completa. Todavia, receberam fotos do momento da ação criminosa. Referiu que do quadro à grade há uma distância de vinte a trinta metros, de maneira que um deles cortava o fio a fim de cessar a energia e permitir que o outro retirasse o conduíte. Contou que os acusados ainda estavam praticando a ação e, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram em sentidos opostos. O corréu Marcelo foi abordado na praça e o corréu Gilberto foi detido mais adiante (gravação audiovisual, pp. 251/252).

Vê-se assim, que o contexto probatório aqui amealhado se revela coerente, harmônico e uníssono, dando ensejo ao desate condenatório.

Sob o crivo do contraditório, os guardas municipais relataram que foram alertados pelo centro de monitoramento do município sobre a ação delitiva dos acusados. Assim, chegando ao local, observaram os réus subtraindo fios de um quadro de energia, os quais, ao perceberem a aproximação da equipe, tentaram fugir, mas acabaram detidos.

Declararam que ambos os acusados possuíam alicates, bem como ambos confessaram informalmente o delito.

Ademais, confirmaram que as características físicas e de vestimentas dos réus correspondiam àquelas informadas pelo setor de monitoramento.

Os acusados, por sua vez, confirmaram que estavam no local dos fatos para subtraírem os fios elétricos.

O corréu Gilberto relatou que, por conta da morte de um morador de rua, o quadro de energia foi desativado e, por tal razão, tentou subtrair os fios, só não conseguindo em razão da chegada dos guardas municipais. Disse, ainda, que encontrou o corréu Marcelo na praça.

Além disso, o corréu Marcelo contou que lhe cabia puxar uma das extremidades do fio enquanto o corréu Gilberto cortava a outra extremidade com um alicate.

Note-se que o laudo pericial de pp. 281/285 confirmou que os alicates encontrados com os réus são instrumentos eficazes para a prática do crime esclarecendo que "As ferramentas descritas como peças de exame, face às suas características, além dos usos formais a que se destinam, se manuseadas com aplicação de esforços musculares, em conjunto ou separadas, poderiam seccionar e romper obstáculos, sistemas de segurança, seccionar fios de bitolas variadas e fraturar peças várias."

Registre-se, ademais, que a ausência das imagens captadas pelo setor de monitoramento da Prefeitura em nada compromete a prova aqui reunida à vista dos seguros depoimentos dos guardas municipais, que revelam que a confissão não poderia ser desprezada.

Desta forma, certo está que a confissão - manifestada sob o crivo do contraditório - encontra seguro conforto na prova aqui reunida, que indica o desate condenatório. Entretanto, é de se atender os reclamos da Acusação e da Defesa, pois se tratou de subtração tentada, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, que se viram surpreendidos e detidos pelos guardas municipais, que rapidamente foram acionados pelo centro de monitoramento do município e encontraram os réus ainda no local.

Assim, forçoso que se reconheça a pretendida desclassificação para reconhecimento do crime de furto na forma tentada.

De outro lado, a qualificadora relativa ao concurso de pessoas é situação perfeitamente configurada, pois é de se reconhecer que os réus estavam efetivamente ajustados e deram cabo à execução do crime de furto.

Inegável, pois, auxílio e cooperação empreendidos pelos acusados, que agiram com unidade de propósitos e perpetraram a tentativa de subtração dos fios do quadro de energia.

E, como já se decidiu:

"...O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas, pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa necessária ao êxito global da infração. Para a caracterização da coautoria no concurso de pessoas é necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, não se exigindo que todos os partícipes tenham consumado atos típicos de execução..." (TJSP; Apelação Criminal 1503167-16.2018.8.26.0229; Rel. Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 11/06/2020). Por final, comprovado está que a conduta criminosa foi praticada durante o repouso noturno, conforme descrito na denúncia, pois o crime ocorreu por volta de 2h45min, ou seja, durante a alta madrugada.

Todavia, não é possível reconhecer caracterizada a ocorrência da causa de aumento de pena do repouso noturno, uma vez que, em recente decisão, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo n.º 1.087, fixou a tese de que: "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (acórdão pendente de publicação).

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Prevalecia, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. Essa orientação, todavia, sofreu overruling. 2. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção do STJ fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 3. Ordem de habeas corpus concedida, para afastar o aumento relativo à majorante prevista no art. 155, § 1.º, do Código Penal". (STJ. HC n. 747.967/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Desta forma, é caso de afastar a incidência desta causa de aumento de pena do repouso noturno.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, em parte, a ação penal.

Passo à individualização da pena.

I - corréu Marcelo Gomes de Moura.

O acusado é reincidente, pois possui condenações definitivas pelos crimes de roubo simples (autos n.º 0021635-83.2012.8.26.0562 - certidões de pp. 90 e 239), furto simples (autos n.º 0005763-23.2010.8.26.0562 - certidões de pp. 89 e 240), violação de direito autoral (autos n.º 0010918-80.2010.8.26.0562 - certidões de pp. 90 e 240) e roubo majorado (autos n.º 1521787-81.2017.8.26.0562 - certidões de pp. 91 e 240). Ademais, ostenta uma condenação definitiva antiga pelo crime de roubo majorado (autos n.º 0016419-15.2010.8.26.0562 - certidões de pp. 90 e 239), a qual, ainda que não sirva para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, continua a macular sua vida pregressa e deixa claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento anterior em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64,

I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...". (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Ainda, responde a outras ações penais envolvendo apuração de crimes de furto qualificado (autos n.º 1500144-72.2022.8.26.0536 e 1500169-85.2022.8.26.0536 – certidão de p. 91), destacando-se que tais apontamentos não serão aqui considerados nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Indiscutível, outrossim, que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o acusado praticou o furto durante a alta madrugada, período em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da diminuição da vigilância exercida sobre a res.

Destaque-se que o local palco dos fatos, Praça dos Andradas, é bastante movimentado durante o dia, pois situa-se próximo ao terminal urbano de passageiros e à estação rodoviária de Santos. Não há dúvida que o fato do crime ter sido praticado durante o repouso noturno permitiu a realização da empreitada criminosa, impedida unicamente em razão da célere atuação dos guardas municipais.

Na hipótese sub judice, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de seus maus antecedentes e das circunstâncias desfavoráveis do crime, aumento a pena-base em 1/4 (um quarto), fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Presente a circunstância agravante da reincidência, aumento a pena em 1/2 (metade), pois se trata de quatro condenações definitivas, três delas por crimes contra o patrimônio (roubo e furto), o que não poderia ser desprezado.

Assim, fixo a pena em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

De outro lado, o acusado confessou a prática da conduta criminosa.

Consoante estabelece o artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

No entanto, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência.

A respeito decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"... REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal. (RHC 141519, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, processo eletrônico dje-223 divulg 08-09-2020 public 09-09-2020).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas.

Afora isso, verifica-se a existência de quatro condenações anteriores em desfavor do acusado, todas aptas a configurar a reincidência, o que desautoriza a concessão da compensação.

E, neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MULTIRREINCENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2º, INC. IV, DO CPP. INEXISTÊNCIA. I - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de

Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013, firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". II - Na hipótese, contudo, verifica-se a inaplicabilidade do referido precedente na medida em que trata-se de acusado multirreincidente, o que inviabilizada a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea conforme entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício. Precedentes (...). (AgRg no AREsp 1810950/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). Assim, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, tratando-se de crime tentado, e à vista do iter criminis percorrido pelo agente e seu comparsa, que chegaram a cortar 4 conduítes do quadro de eletricidade (p. 11), diminuo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique. Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reincidência, representada por condenações definitivas por roubo e furto, e evidenciados os maus antecedentes e as circunstâncias desfavoráveis do crime, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, este não só em razão do quantum de pena aplicada, mas especialmente em razão da reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não havendo informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

II - corréu Gilberto Oliveira Ribas

O acusado é reincidente, pois possui condenações definitivas pelos crimes de roubo (autos n.º 0000211-24.2016.826.0625, certidão de p. 104), desacato (autos n.º 1500393-34.2018.826.0028, certidões de pp. 98 e 246) e porte ilegal de droga para consumo pessoal (autos n.º 0008735-12.2014.8.26.0073 - certidão de p. 99). Ademais, ostenta condenações definitivas antigas pelos crimes de roubo majorado (autos n.º 0000222-68.1999.8.26.0562 - certidões de pp. 105 e 244; e autos n.º 0064469-58.2006.8.26.0224 - certidão de pp. 101), furto qualificado (autos n.º 0008480-96.2001.8.26.0562 ou 915/2001 - certidões de p. 106 e pp. 244/245), roubo simples tentado (autos n.º 0004790-88.2003.8.26.0562 ou 438/2003 - certidões de pp. 105 e 245), porte ilegal de drogas para uso próprio (autos 0004334-38.2012.8.26.8.26.0073 - certidão de pp. 99; autos n.º 0003355-79.2003.8.26.0562 ou 196/2003 - certidões de pp. 105 e 245; e autos n.º 0000248-58.2011.826.0073 - certidões de pp. 98 e 247), dano qualificado (autos n.º 0013077-42.2009.8.26.0073 - certidão de p. 99), furto simples tentado (autos n.º 0006669-13.2015.826.0562 - certidões de pp. 105 e 245/246) e desacato (autos n.º 0001850-27.2009.8.26.0438, 0001284-78.2009.8.26.0438 e 0001845-05.2009.8.26.0438 - certidão de p. 103), as quais, ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, continuam a macular sua vida pregressa e deixam claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento anterior em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...". (AgRg no HC

509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Indiscutível, outrossim, que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o acusado praticou o furto durante a alta madrugada, período em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da diminuição da vigilância exercida sobre a res.

Destaque-se que o local palco dos fatos, Praça dos Andradas, é bastante movimentado durante o dia, pois situa-se próximo ao terminal urbano de passageiros e à estação rodoviária de Santos. Não há dúvida que o fato do crime ter sido praticado durante o repouso noturno permitiu a realização da empreitada criminosa, impedida unicamente em razão da célere atuação dos guardas municipais.

Assim, na hipótese sub judice, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de seus péssimos antecedentes, representados por doze condenações definitivas antigas por crimes como roubo simples e majorado, furto simples e qualificado, desacato, dano qualificado e porte ilegal de drogas para consumo pessoal, bem como considerando as circunstâncias desfavoráveis do crime, aumento a pena-base em 1/2 (metade), fixando-a em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Presente a circunstância agravante da reincidência, aumento a pena em 1/4 (um quarto), pois se trata de três condenações definitivas, uma delas por crime contra o patrimônio, o que não poderia ser desprezado.

Assim, fixo a pena em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

De outro lado, o acusado confessou a prática da conduta criminosa.

Consoante estabelece o artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

No entanto, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência.

A respeito decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"... REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal. (RHC 141519, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, processo eletrônico dje-223 divulg 08-09-2020 public 09-09-2020).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas.

Afora isso, verifica-se a existência de três condenações anteriores em desfavor do acusado, todas aptas a configurar a reincidência, o que desautoriza a concessão da compensação.

E, neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2º, INC. IV, DO CPP. INEXISTÊNCIA. I - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013, firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". II - Na hipótese, contudo, verifica-se a inaplicabilidade do referido precedente na medida em que trata-se de acusado multirreincidente, o que inviabilizada a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea conforme entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício. Precedentes (...)" (AgRg no AREsp 1810950/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021).

Assim, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, tratando-se de crime tentado, e à vista do iter criminis percorrido pelo agente e seu comparsa, que chegaram a cortar 4 conduítes do quadro de eletricidade (p. 11), diminuo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reincidência, e evidenciados os maus antecedentes, representados por doze condenações definitivas antigas, bem como as circunstâncias desfavoráveis do crime, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, face a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não havendo informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para:

a) condenar MARCELO GOMES DE MOURA, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;

b) condenar GILBERTO OLIVEIRA RIBAS, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcarão os réus com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réus a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenham condições de arcarem com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Os acusados viram convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. É certo que o fato aqui apurado desassossega a sociedade, compromete a paz social e desequilibra a ordem pública. Trata-se de crime cometido mediante concurso de pessoas e durante o repouso noturno.

Assim, a prisão por sentença condenatória recorrível se revela necessária, seja para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como para resguardo da ordem e paz públicas.

Lembre-se que o corréu Marcelo é multireincidente e ostenta maus antecedentes, possuindo condenações definitivas por crimes de furto e roubo, além de se ver processado por dois crimes de furto, ao passo que o corréu Gilberto ostenta maus antecedentes por doze condenações definitivas antigas e é reincidente por crime contra o patrimônio.

Desta forma, é forçoso reconhecer que essa situação não revela que sejam eles pessoas de boa conduta social, mantendo vida desregrada e fazendo da criminalidade e do ataque ao patrimônio alheio seu meio de vida.

Por final, necessário registrar que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para acautelar o procedimento, agora julgado nesta Instância, sendo forçoso reconhecer que, em liberdade, os acusados poderão por em risco a aplicação da lei penal, pois condenados a cumprir pena em gravoso regime.

Assim, recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 27 de junho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA